

《【문제17.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였고, 법원은 소송 계속 중 양 당사자의 합의를 이끌어내기 위해 `화해권고결정`을 내렸다. 甲과 乙 모두 결정서를 송달받은 날로부터 2주 이내에 이의를 신청하지 않아 위 결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지게 되었다. 그런데 3개월 뒤 乙은 위 화해권고결정의 기초가 된 갑 제출의 영수증이 위조된 것임을 알게 되었다.

한편, 丙은 丁을 상대로 물품대금 지급을 구하는 `지급명령`을 신청하였고, 丁이 이의를 제기하지 않아 지급명령이 확정되었다. 그러나 이후 丁은 丙이 지급명령 신청 당시 丁의 주소를 허위로 기재하여 송달받지 못하게 함으로써 방어할 기회를 박탈당했다는 사실을 깨달았다. 丁은 이미 확정된 지급명령의 효력을 제거하고자 한다.

또한, 소송법상 `조정`이 성립하여 조정조서가 작성된 경우에도 당사자 일방이 조정 성립 과정에 중대한 절차적 하자가 있음을 이유로 그 효력을 다투려 하고 있다. 이들은 모두 일반적인 재심의 소가 아닌 `준재심`의 방법으로 구제받을 수 있는지 의문이다.

(물음2) 丙이 丁을 상대로 얻은 확정된 지급명령에 대하여 丁이 준재심을 제기할 수 있는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 판단하고, 조정조서나 재판상 화해와 같이 `판결`이 아닌 처분권주의가 적용되는 조서에 대한 준재심 사유의 특수성을 재심사유와 비교하여 논하시오.》

<문제17.5의 물음2> 확정된 지급명령에 대한 준재심 제기 가능성 및 조서의 특수성에 따른 준재심 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 丁은 확정된 지급명령이 허위 주소 기재로 인해 송달받지 못한 상태에서 확정되었음을 이유로 그 효력을 다투고자 하고, 조정조서 등에 대해서도 준재심으로 다룰 수 있는지가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <확정된 지급명령에 대한 준재심의 허용 여부와 판결이 아닌 조정조서·재판상 화해 등에 대한 준재심 사유의 특수성을 재심사유와 비교>하여 검토할 필요가 있다. 이하에서는 지급명령에 대한 준재심의 허용 여부와 조정조서 등에 대한 준재심 사유의 특수성을 논한다.

1. 지급명령의 효력 및 구제수단

(1) 지급명령의 효력

- "민사소송법 제474조"에 따라 확정된 지급명령은 확정판결과 같은 효력을 가진다. 다만 판결과 달리 기판력이 인정되는지에 대해서는 견해의 대립이 있으나, "민사집행법 제58조 제3항"은 확정된 지급명령에 대한 청구이의의 소에서 기판력의 시간적 한계에 따른 제한을 두지 않고 있다.

(2) 구제방법의 분화

- 확정된 지급명령의 효력을 배제하기 위한 방법으로는 청구이의의 소("민사집행법 제58조")가 일반적이다. 사안처럼 송달의 하자가 있는 경우에는 준재심의 소를 제기할 수 있는지에 대한 판례의 검토가 요구된다.

2. 판례의 태도

(1) 준재심 부정설

- "판례"는 확정된 지급명령에 대하여 "민사소송법 제461조"가 정한 준재심의 소를 제기할 수 없다는 입장이다. 지급명령은 기판력이 없으므로 그 효력을 다투기 위해서는 청구이의의 소를 제기하거나, 송달 자체가 부적법하여 확정되지 않았음을 주장하며 이의신청 및 추완이의를 하는 방식으로 해결해야 한다고 본다.

(2) 사안의 경우

- 사안에서 丁은 丙이 주소를 허위 기재하여 송달을 가로챘음을 주장하고 있다. "판례"에 따르면 이 경우 지급명령은 적법하게 송달된 것으로 볼 수 없어 확정되지 않았으므로, 丁은 준재심을 제기할 것이 아니라 지급명령에 대한 이의신청을 하거나 청구이의의 소를 통해 다투어야 한다.

II. 조서에 대한 준재심 사유의 특수성

1. 재판상 화해 및 조정조서의 성질

(1) 이원적 성격

- 재판상 화해나 조정조서는 소송법상 판결과 동일한 효력을 가지는 소송행위인 동시에, 당사자 간의 합의라는 사법상 계약의 성격을 병유한다.

(2) 처분권주의의 발현

- 판결이 법원의 판단에 의한 것인 반면, 조서는 당사자의 의사 합치에 기초한다. 따라서 그 효력을 다투는 사유 역시 판결에 대한 재심사유와는 차이가 발생할 수밖에 없다.

2. 준재심 사유의 확장 여부(사법상 하자)

(1) 원칙(재심사유 한정)

- "민사소송법 제461조"는 "제451조"의 재심사유를 준용한다고 규정하므로, 원칙적으로 법문에 열거된 재심사유가 있어야만 준재심이 가능하다.

(2) 특수성(실체법상 하자)

- 재판상 화해나 조정은 사법상 합의를 기초로 하므로, 합의 자체에 민법상 무효나 취소 사유(의사표시의 착오, 사기, 강박 등)가 있는 경우 이를 준재심 사유로 인정할 것이냐가 핵심이다. "판례"는 화해조서 등의 내용이 실체법상 계약의 원인 무효 사유가 있더라도 그것이 민사소송법이 정한 재심사유에 해당하지 않는 한 준재심의 소를 제기할 수 없다는 태도를 견지해 왔다.

3. 재심사유와 비교한 특수성

(1) 절차적 하자의 중시

- 조서의 경우 "제451조 제1항 제3호"(당사자의 대리권 흠결) 등 절차적 공정성을 해치는 사유가 준재심에서 핵심적으로 다루어진다.

(2) 사법상 하자의 포섭 노력

- 비록 "판례"는 엄격히 재심사유에 한정하나, 해석상 "제451조 제1항 제9호"(판결의 기초가 된 재판의 변경) 등을 원용하여 실체법상 하자를 간접적으로 수용하려는 학설적 시도가 존재한다. 그러나 현행 실무상 판결에 대한 재심보다 의사의 합치라는 성립 요건의 하자가 더 중요하게 다루어진다는 점이 조서 준재심의 특수성이다.

III. 사안의 적용

1. 지급명령에 대한 丁의 불복

- 丁이 제기하려는 준재심은 “판례”의 태도에 비추어 볼 때 부적법하다. 丁은 주소 허위 기재 및 송달 불능을 근거로 지급명령 이의신청(또는 추완이의)을 하거나, 집행력을 배제하기 위한 청구이의의 소를 제기하는 것이 타당한 구제수단이다.

2. 조정조서에 대한 불복

- 조정 성립 과정에 중대한 절차적 하자가 있다는 주장은 "민사소송법 제461조" 및 "제451조 제1항" 소정의 사유(예 : 대리권의 흠결 등)에 해당할 경우 준재심의 소를 통해 다룰 수 있다. 다만 단순히 조정 내용이 불공정하다거나 사법상 착오가 있었다는 사유만으로는 “판례”상 준재심 청구가 기각될 가능성이 높다.

V. 결론

- 확정된 지급명령은 기판력이 없고 별도의 불복 방법이 존재하므로 준재심의 대상이 되지 않는다는 것이 확립된 “판례”이다. 또한 재판상 화해나 조정 조서에 대한 준재심은 판결과 달리 사법상 계약의 성질을 가지나, 우리 법제는 법적 안정성을 위해 민사소송법상 열거된 재심사유가 있는 경우에 한하여 준재심을 허용하므로 청구인은 이를 엄격히 증명하여야 한다.